



République du Sénégal

République du Sénégal
Un Peuple - Un but - Une Foi
Primature



AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS



MANUEL DE GESTION DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Mai 2017

SOMMAIRE

1.	Les étapes préalables au lancement d'une procédure de passation	7
1.1	Étude de faisabilité juridique et réalisation du rapport d'opportunité	8
1.1.1	Analyser les caractéristiques du service public	8
1.1.2	Choisir le montage juridique le plus approprié	9
1.2	Consulter la société civile sur le projet de délégation de service public	13
1.2.1	Évaluation du potentiel commercial du contrat	13
1.2.1.1	Intérêt des partenaires potentiels	13
1.2.1.2	Bancabilité du projet	23
1.3	La mise en place d'une équipe dédiée	14
1.3.1	Organiser le pilotage du projet en interne	15
1.3.1.1	Monter une équipe projet	16
1.3.1.2	Désigner un directeur de projet	16
1.3.1.3	Engager des conseils externes	16
1.3.2	Calendrier prévisionnel	17
2.	La préparation du lancement du processus de passation du contrat	18
2.1	Choisir la procédure de passation du contrat	19
2.2	Déterminer les critères d'attribution du contrat	19
2.3	Rédiger le dossier de consultation	19
2.3.2	Les pièces du dossier d'appel à la concurrence	19
2.3.3	La consultation de la DCMF	21
3.	La passation du contrat de DSP	23
3.1	Organiser la publicité des documents de la consultation	24
3.1.1	La publicité du dossier d'appel à la concurrence	24
3.1.2	Support de la publication	24
3.2	Procéder à la sélection des candidatures	25
3.2.1	Les justifications exigées	25
3.2.1.1	Interdictions de soumissionner	25
3.2.1.2	Capacités techniques	26
3.2.1.3	Capacités professionnelles	26
3.2.1.4	Capacités financières	26
3.2.2	Retenir 3 à 5 candidats	27
3.3	Négocier avec les candidats présélectionnés	27
3.3.1	Le délai de présentation des offres	27
3.3.2	La libre négociation des offres	28
3.3.3	Les principes cardinaux à respecter	29

3.4	Sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse	29
3.4.1	Détermination des critères d'évaluation des offres	29
3.4.2	Modalités d'évaluation des critères	30
3.4.3	Évaluation des offres	30
3.4.4	Classement des offres	31
3.4.5	Transfert de technologie et de savoir-faire	31
3.5	La fin de la procédure de passation	31
3.5.1	Information des candidats évincés	31
3.5.2	La signature du contrat	32
3.5.3	Publication d'un avis d'attribution	32
4.	L'exécution des contrats de DSP	34
4.1	Suivi et contrôle	35
4.1.1	Le contrôle de l'exécution du contrat	35
4.1.2	Le rapport annuel	35
4.1.3	Détermination des responsabilités	38
4.1.4	Suivi de la performance du contrat	38
4.2	Les modifications du contrat de DSP	39
4.2.1	Les modifications unilatérales	40
4.2.2	Rédiger un avenant	40
4.2.3	Refinancement	41
4.3	Sanctionner son cocontractant	41
4.3.1	Choisir une sanction proportionnée	41
4.3.2	Mettre en œuvre une sanction	42
4.4	La résiliation d'un contrat de DSP	43
4.4.1.1	Choisir le motif de la résiliation	43
4.4.1.2	La résiliation pour motif d'intérêt général	44
4.4.1.3	La résiliation pour faute	44
4.4.2	Respecter le principe du contradictoire	44
4.4.3	Définir les modalités d'indemnisation	45
5.	La fin des contrats de DSP	47
5.1	Conséquences financières de la fin de contrat	48
5.2	Réaliser un inventaire des biens	48
5.3	Assurer la continuité du service public	50
6.	Règlement non-juridictionnel des litiges : le cas de l'arbitrage	52

Abréviations, acronymes et sigles

AAC : Avis d'appel à la concurrence

ARMP : Autorité de Régulation des Marchés publics

CCI : Chambre de Commerce et Industrie de Paris

CCJA OHADA : Cour commune de Justice et d'Arbitrage de l'Organisation pour l'Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires

CGCL : Code général des Collectivités locales

CIRDI : Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements

CMP : Code des Marchés publics

COA : Code des Obligations de l'Administration

COCC : Code des Obligations civiles et commerciales

DCMP : Direction centrale des Marchés publics

CR : Conseil de Régulation

CRD : Comité de Règlements des Différends

DSP : Contrat de délégation de service public

GER : Gros entretien et de renouvellement du matériel

PAP : Plan d'actions prioritaires

PPP : Partenariat public-privé lato sensu

PSE : Plan Sénégal Émergent

UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine



PRÉFACE

SAER NIANG

Directeur Général ARMP

Dans le cadre de sa mission de modernisation des procédures et des outils de passation des marchés publics et des délégations de service public, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), celle-ci a réalisé une étude visant à améliorer le dispositif juridique et institutionnel relatif à la passation, l'exécution et le contrôle des conventions de délégation de service public. C'est dans ce cadre que le présent manuel de gestion des délégations de service public a été élaboré.

A travers ce document, l'ARMP met à la disposition des acteurs de la commande publique un instrument qui leur permettra :

- d'asseoir une meilleure compréhension du contexte sénégalais de gestion des délégations de service public ainsi que des modalités pratiques de mise en œuvre desdites conventions de lever les incompréhensions qui peuvent affecter les objectifs de transparence, de célérité et d'efficacité de la passation et de la réalisation des délégations de service public ;
- de mitiger les risques liés à un déficit d'information et d'instruments juridiques dans le domaine.

De façon spécifique, ce manuel de gestion pourra efficacement guider l'action des autorités contractantes souhaitant externaliser la gestion d'un service public, tout au long de la procédure de passation et de mise en œuvre, des étapes préalables à la fin du contrat. Il présente, de manière chronologique, l'ensemble des étapes associées au cycle de vie d'une convention de délégation de service public et les bonnes pratiques associées à chacune de ces phases.

L'ARMP adresse ses vifs remerciements au Programme de coopération bilatérale Sénégal-Luxembourg, à travers son Bureau régional Lux-Développement, pour l'appui à la réalisation de l'étude sur les délégations de service public (DSP) au Sénégal.



1. LES ÉTAPES PRÉALABLES AU LANCEMENT D'UNE PROCÉDURE DE PASSATION



AUTORITE
DE REGULATION DES
MARCHES PUBLICS

Direction Générale
Centre de Formation

Rue Alpha Hachamiyou TALL x KLEBER
BP : 11 303

1.1.Étude de faisabilité juridique et réalisation du rapport d'opportunité

L'article 82.2 du Code des Marchés publics impose à toute autorité susceptible de déléguer la gestion d'un service public en vertu du droit sénégalais de la commande publique (ci-après une « Autorité délégante »), de rédiger un rapport d'opportunité préalablement au lancement de la procédure de passation du contrat .

Pour les besoins de ce rapport, et afin d'en faciliter la rédaction, il pourrait être utilement précédé d'une étude de faisabilité juridique, qui comprend les éléments techniques, juridiques et financiers qui doivent aider à la décision de recourir à la DSP.

Cette première partie vise à rappeler la façon dont la personne publique responsable du service devra aborder la rédaction de ce rapport.

1.1.1.Analyser les caractéristiques du service public

En premier lieu, le rapport d'opportunité doit faire ressortir l'organisation et le mode de gestion du service public, s'il existe. Cette première phase doit conduire la personne publique à recueillir le plus d'informations possible sur le service public dont il envisage de déléguer la gestion.

Ce dernier peut être géré en régie, c'est-à-dire directement par la personne publique responsable du service, ou avoir déjà fait l'objet d'une convention de délégation de service public. Dans cette dernière hypothèse, la personne publique devra pouvoir s'appuyer sur les informations transmises par l'ancien délégataire de service public, et en particulier sur les rapports annuels qui auront été rédigés par le délégataire.

À l'issue de cette phase, un premier état des lieux de la gestion du service public doit pouvoir être établi.

En second lieu, la personne publique en charge du service doit formaliser un ensemble d'évolutions souhaitées du service public, s'il existe déjà.

Ce moment doit être l'occasion pour la personne publique en charge du service de fixer un certain nombre d'objectifs qu'il conviendra d'atteindre en matière d'investissements, de qualité de gestion ou encore de tarifs proposés aux usagers.

En troisième lieu, s'il est envisagé de créer un nouveau service public, le rapport d'opportunité doit permettre :

- de fixer les principales caractéristiques de ce service. Dans ce cas, la personne publique doit s'assurer que la création du service public relève bien de son domaine de compétence, et qu'elle n'empiète pas sur les compétences d'une autre personne publique ;
- d'identifier les indicateurs de performance permettant d'évaluer la performance du service public dont la gestion sera déléguée. Ainsi en face du prix perçu par exemple sur les usagers, il convient en permanence de s'assurer que l'obtention de la qualité requise ne se fait pas au détriment de la valorisation patrimoniale. Il apparaît donc souhaitable que les indicateurs permettent de vérifier la bonne gestion de cet équilibre entre les objectifs de court terme et ceux de long terme.

1.1.2. Choisir le montage juridique le plus approprié

La dernière partie du rapport d'opportunité est particulièrement importante car elle doit permettre à la personne publique de présenter le montage contractuel qu'elle considère être le plus adapté compte tenu de l'analyse qu'elle aura préalablement effectuée.

À cet égard, il convient de rappeler que la personne publique responsable du service public est libre de choisir le mode de gestion du service public qu'elle souhaite privilégier. En tout état de cause, si elle souhaite externaliser la gestion du service public, elle devra choisir entre ces trois catégories de contrat :

- le contrat de concession : il s'agit d'un contrat confiant à son titulaire, non seulement l'exploitation d'un service public, mais aussi le financement et la construction, ou l'acquisition des biens nécessaires à ce service ;
- le contrat d'affermage : c'est une catégorie de délégation de service public permettant de confier, à un délégataire appelé « fermier », l'exploitation d'un service public, sans que celui-ci n'assure l'établissement des ouvrages et biens nécessaires au service ;
- le contrat de régie intéressée : c'est un contrat par lequel la collectivité va confier à une personne, le régisseur, la gestion d'un service public qui assure le contact avec les usagers, exécute les travaux, mais qui agit pour le compte de la collectivité.

L'étude comparative de ces formules contractuelles ne doit pas se résumer à une présentation générale des avantages et inconvénients de chacun de ces contrats, mais prendre en compte les spécificités inhérentes au service public.

Il convient également que la personne publique établisse une matrice des risques.

En matière de DSP au sens large, les risques principaux sont classiquement répartis de la façon suivante :

Identification des risques	Prise en charge du risque			Commentaires / exemples
	Par la personne publique	Par l'opérateur économique	Risque partagé	
Risques de conception		x		Changement de conception (à la demande du constructeur, ou requis par les autorités d'urbanisme, de prévention incendie, etc.), etc.
Autorisations administratives				Obtention des permis, etc.
Risques de construction		x		Coût et délais mal estimés, difficultés imprévues pour les fondations, vol de matériel sur le site, incapacité à garantir le respect de la réglementation du travail sur le chantier, défaut de sous-traitants, vices cachés, etc.
Risques géologiques			x	Risques du sol : si des études existent, le risque est privé.
Exploitation-maintenance		x		Défaillance de maintenance de l'ouvrage sur la durée de la DSP, non-délivrance du service aux usagers, hausse des coûts de maintenance et des équipements, etc.
Acquisitions foncières		x		
Qualité et disponibilité du service		x		
Risque commercial		x		Également dit risque « trafic », lié à l'exploitation du service public
Renouvellement des installations		x		
Risque contentieux contre la DSP	x			
Évolution technologique		x		
Force majeure			x	
Imprévision			x	
Changement de loi			x	Changements légaux et fiscaux discriminatoires et spécifiques au projet (ex : règles sanitaires et sécuritaires), etc.

Identification des risques	Prise en charge du risque			Commentaires
	Par la personne publique	Par l'opérateur économique	Risque partagé	
Exploitation-maintenance				
Acquisitions foncières		x		
Qualité et disponibilité du service		x		
Risque commercial		x		Également dit risque « trafic », lié à l'exploitation du service public
Renouvellement des installations		x		
Risque contentieux contre la DSP	x			
Évolution technologique		x		
Force majeure			x	
Imprévision			x	
Changement de loi			x	Changements légaux et fiscaux discriminatoires et spécifiques au projet (ex : règles sanitaires et sécuritaires), etc.

Identification des risques	Prise en charge du risque			Commentaires / exemples
	Par la personne publique	Par l'opérateur économique	Risque partagé	
Risques de conception	x			
Autorisations administratives			x	Autorisations relatives à l'ouvrage public.
Risques de construction	x			Frais de premier établissement du service (investissement et fonctionnement)
Risques du sol	x			
Exploitation-maintenance				
Acquisitions foncières	x			
Qualité et disponibilité du service			x	
Risque commercial			x	Également dit risque « trafic », lié à l'exploitation du service public
Renouvellement des installations		x		
Risque contentieux contre la DSP	x			
Évolution technologique	x			
Force majeure			x	
Imprévision			x	
Changement de loi			x	Changements légaux et fiscaux discriminatoires et spécifiques au projet (ex : règles sanitaires et sécuritaires), etc.

À l'issue de ce rapport, la personne publique doit pouvoir présenter les principales caractéristiques du contrat qu'elle envisage de conclure, et notamment :

- **l'objet du contrat ;**
- **le périmètre du service délégué ;**
- **la durée envisagée du contrat.**

Enfin, une fois le rapport adopté par la personne publique, il doit être remis pour avis à la Direction centrale des Marchés publics (ci-après la « DCMP »).

Nous avons recommandé, à cet égard, qu'un texte législatif ou réglementaire fixe à cette autorité un délai pour rendre son avis sur la note d'opportunité, afin de limiter la durée totale de la procédure de passation d'une délégation de service public.

1.2.Consulter la société civile sur le projet de délégation de service public

Conformément à nos recommandations, il apparaît souhaitable de prévoir un mécanisme de consultation de la société civile, et plus précisément des usagers du service public et d'associations en lien avec le service sur le projet de DSP.

Cette consultation pourrait être réalisée à travers la mise en place alternative d'une commission consultative, la tenue d'audiences ou de séances publiques, dont les modalités restent à définir.

En tout état de cause, cette commission devra être consultée sur la base des éléments contenus dans ce rapport. La personne publique ayant rédigé le rapport d'opportunité devra être attentive aux besoins et attentes exprimées par les usagers dans le cadre de la consultation de cette commission ou des audiences ou séances publiques.

La consultation de ladite commission ou la tenue des audiences ou séances publiques ne peuvent conduire à bloquer la procédure de passation du contrat de délégation de service public. C'est pourquoi l'avis de ladite commission ne pourra être que consultatif.

Il peut être recommandé à la personne publique de modifier éventuellement certaines caractéristiques du contrat qu'elle entend conclure, afin de prendre en compte l'avis exprimé par les représentants des usagers et les associations.

1.2.1. Évaluation du potentiel commercial du contrat

1.2.1.1. Intérêt des partenaires potentiels

Il y a lieu de consacrer du temps et des efforts à l'établissement d'une présentation claire du projet de DSP, afin de susciter l'intérêt des partenaires potentiels.

Différents éléments peuvent susciter l'intérêt des potentiels délégataires :

- **la dimension du projet de DSP peut être déterminante. Un projet d'une « petite » dimension pourrait ne pas intéresser les délégataires au regard des importants coûts de mise en œuvre du projet. Au contraire, un projet d'une très grande envergure soulève la question de la capacité du délégataire à répondre aux importants besoins du projet.**

- **les technologies utilisées dans le cadre du projet sont également un élément fondamental. Les délégataires montreront peu d'intérêt pour les projets nécessitant l'utilisation de technologies d'avant-garde encore non éprouvées au travers d'autres marchés de DSP.**
- **la gestion du personnel a une influence notable sur l'intérêt des candidats au regard des charges importantes que peuvent induire les éventuels transferts de main d'œuvre nécessaires dans le cadre de certains projets de DSP.**

Néanmoins, le critère déterminant pour le délégataire potentiel demeure l'aspect financier. Les partenaires seront intéressés par le projet uniquement si l'ensemble des coûts établis peut être couvert par les recettes prévues, ce qui recouvre également d'autres critères, comme l'octroi de subventions publiques.

Plus généralement, il est nécessaire de présenter les principaux éléments du projet détaillés plus haut de façon claire et précise. Le but est de traduire le projet initial en termes commerciaux en précisant les résultats requis, les responsabilités et les risques encourus par les différentes parties prenantes ou encore les modalités de collecte des recettes. Une présentation claire et précise de ces différents éléments est essentielle pour susciter l'intérêt des partenaires potentiels.

Dans la perspective de convaincre les partenaires intéressés, l'Autorité délégante peut s'appuyer sur des projets de DSP similaires ayant fonctionné dans des pays voisins. Par ailleurs, la réalisation préalable d'études ou de sondages de marché peut être déterminante pour susciter l'intérêt des potentiels délégataires.

1.2.1.2. Bancabilité du projet

Avant de s'engager dans un projet de DSP, les délégataires potentiels souhaitent s'assurer que le projet de DSP est « bancable », ou viable économiquement. Un projet est dit « bancable » lorsqu'il s'appuie sur un solide plan financier, économique et technique.

La « bancabilité » d'un projet de DSP est évaluée selon les axes suivants :

• La stabilité économique et politique du pays.

Les partenaires potentiels souhaiteront déterminer comment l'économie locale et le projet s'influenceront mutuellement. S'il est vrai que c'est le délégant, et non les partenaires potentiels, qui devrait s'assurer que le projet aura une incidence positive globale sur le pays concerné et l'économie locale, les partenaires potentiels doivent évaluer les avantages politiques et socio-économiques nets que le projet présente, d'une manière générale, pour le pays. Une mesure fréquemment utilisée est le taux de rentabilité économique (ci-après le « TIRE »), c'est-à-dire le taux de rentabilité du projet après la prise en compte des coûts et des avantages économiques, notamment les coûts et avantages monétaires. Le TIRE tient compte des externalités (tels que les avantages sociaux et environnementaux) qui ne sont pas incluses dans le calcul du taux de rentabilité financière.

Les partenaires potentiels se serviront aussi de cette évaluation à l'échelle macroéconomique pour poser quelques questions fondamentales au sujet du projet :

- les tendances rétrospectives et tendances futures probables en matière de prix, production, disponibilité, qualité, concurrence, demande et nature de la demande ;
- l'identification et l'emplacement du fournisseur d'intrants et d'autres prestataires de services ;
- la souplesse, la sophistication, le degré de qualification et la profondeur du marché du travail ;
- les tendances rétrospectives et les tendances futures probables en ce qui concerne le taux d'inflation, les taux d'intérêt, les opérations de change, le coût et la disponibilité de la main-d'œuvre, de l'équipement et des services (tels que l'eau, l'électricité et les télécommunications) ;
- l'état des infrastructures locales ;
- la charge administrative pesant sur les importations, en particulier sur l'équipement et la main-d'œuvre spécialisés.

• **Le cadre technique**

Les technologies nécessaires au projet peuvent représenter un risque financier important, particulièrement dans le cas des technologies avant-gardistes, pouvant avoir une influence sur la bancabilité du projet. Par ailleurs, certaines technologies ne peuvent être utilisées que suite à l'obtention d'un droit d'usage.

• **Le cadre juridique**

Une attention particulière sera portée par les partenaires potentiels à l'accès aux systèmes juridique et fiscal, au cours des différentes étapes de la mise en œuvre du projet de DSP.

• **Le cadre financier**

Afin de déterminer la bancabilité du projet de DSP, il est nécessaire d'élaborer un modèle financier projetant les flux de trésorerie sur la durée prévue du contrat de DSP. Le modèle financier doit présenter les flux de trésorerie nécessaires au remboursement des emprunts. L'évaluation des coûts du projet débouche sur une estimation des recettes nécessaires à les couvrir lorsque les usagers paient directement la « société de projet » pour le service fourni, l'Autorité et ses conseillers doivent examiner la capacité et la volonté de payer des usagers, en particulier lorsqu'il est nécessaire d'alourdir la tarification du service pour atteindre les objectifs de recettes. Dans de nombreux cas, le secteur public devra subventionner le service pour le rendre abordable pour les usagers. Le recours aux subventions publiques peut cependant avoir une incidence sur le bilan coûts/avantages de la convention.

Plus généralement, une évaluation des ratios financiers sera faite afin de déterminer la viabilité financière de la structure du projet.

1.3. La mise en place d'une équipe dédiée

1.3.1. Organiser le pilotage du projet en interne

La passation de la DSP requiert l'instauration d'une équipe dédiée au sein de l'Autorité délégente afin d'assurer un suivi efficace et constant. Il s'agit le plus souvent de la cellule dédiée

à la passation des contrats.

Il n'existe pas de modèle universel, mais des éléments récurrents peuvent être retenus comme base.

1.3.1.1. Monter une équipe projet

Au sein de l'Autorité délégante, il convient d'arrêter une équipe de gestion dédiée au projet et qui accompagne sa mise en œuvre au quotidien.

Sous la direction du directeur de projet, elle devra inclure des spécialistes techniques, juridiques, financiers, opérationnels, ou relevant de tout autre domaine exigé par le projet.

1.3.1.2. Désigner un directeur de projet

Le directeur du projet tient un rôle clé dans le succès de ce dernier. Il s'agit d'une fonction à temps plein, incluant la supervision des différentes étapes de la mise en place du projet et la coordination de l'ensemble des intervenants, qu'il s'agisse des organismes de gestion interne ou des conseillers extérieurs.

Le directeur de projet devra disposer de compétences avérées en affaires, notamment en négociation contractuelle. De plus, il devra connaître le fonctionnement des institutions administratives prenant part au projet, ainsi que leur processus de décision.

1.3.1.3. Engager des conseils externes

Lors du montage du projet, l'Autorité délégante peut ne pas disposer de toute l'expertise nécessaire en interne. Elle devra faire appel à des conseils extérieurs expérimentés afin de venir appuyer le travail de l'équipe de gestion.

Les conseils seront amenés à intervenir dès le stade de l'étude de faisabilité. Il est donc impératif de les sélectionner à temps, en amont du projet. Leur recrutement présente, par ailleurs, un coût important qu'il faudra prendre en compte dès l'établissement du budget initial. Un plan détaillé des missions et des interventions des conseillers aux différentes étapes du contrat devra être défini et reflété sous la forme de chronogramme avec : les acteurs, les dates et les durées d'interventions.

Pour la phase de passation, l'équipe de conseillers comprend en principe un conseiller financier, un conseiller technique, un conseiller juridique et un conseiller en passation des marchés. Selon les spécificités du projet, d'autres consultants peuvent également être sollicités (des spécialistes environnementaux par exemple).

Les missions respectives de chaque conseiller seront définies avec précision dans le mandat. Un panorama non exhaustif des missions de chacun peut être dressé comme suit :

Conseillers juridiques :

- assistance dans la faisabilité juridique du projet ;
- conseil sur la procédure de passation du contrat ;
- conseil et rédaction de l'avis d'appel public à la concurrence ;
- préparation de la documentation relative à la passation du contrat, notamment le dossier

d'appel d'offres comprenant : le cahier des charges (respectivement le programme fonctionnel, dans le cadre d'un dialogue compétitif), les critères d'évaluation des offres, les critères de qualification, le projet de contrat, etc. ;

- négociation et revue du contrat ;
- bouclage juridique du contrat (levée notamment, et le cas échéant, des conditions suspensives).

Conseillers financiers :

- assistance dans la structuration de tous les aspects financiers du projet ;
- détermination des sources de financement publiques envisageables ;
- cadres financiers (tarifications, subventions, compensations,...) ;
- examen, voir audit, des propositions financières des candidats, notamment de leur robustesse et de leur conformité aux prérequis ;
- assistance à la définition d'une stratégie de couverture des risques liés aux taux d'emprunt ou aux taux de change ;
- bouclage du montage financier ;
- assistance au comité technique chargé de l'évaluation des propositions financières

Conseillers techniques :

- réalisation d'études techniques préalables relatives à la faisabilité du projet ;
- rédaction du cahier des charges du projet ou du programme fonctionnel (en cas de dialogue compétitif) ;
- définition des critères de performance ;
- définition du mécanisme de paiement ;
- analyse des solutions proposées par les candidats.

Conseiller environnemental :

- analyse des incidences environnementales du projet ;
- assistance pour l'obtention des autorisations et permis nécessaires à la réalisation du projet ;
- identification des risques environnementaux et des propositions de prévention fournies par les candidats.

Spécialiste en passation des marchés, notamment chargé d'identifier la réglementation applicable en vue de sa bonne application.

1.3.2. Calendrier prévisionnel

L'une des premières tâches de l'équipe de gestion est de développer un calendrier détaillé pour le montage du projet. Chaque projet présente des spécificités justifiant la mise en place d'un calendrier différent.

Il est essentiel que le calendrier proposé soit supporté par toutes les parties prenantes au projet. Le respect du calendrier est fondamental afin d'éviter des retards en cascade.



2. LA PRÉPARATION DU LANCEMENT DU PROCESSUS DE PASSATION DU CONTRAT



2.1. Choisir la procédure de passation du contrat

Le choix de la procédure de passation du contrat doit constituer la première interrogation de l'Autorité délégante, car il conditionne la suite de la procédure de passation.

En premier lieu, l'Autorité délégante doit s'interroger sur l'existence d'une situation permettant de recourir à la passation du contrat sans publicité et mise en concurrence, c'est-à-dire par entente directe.

Si tel est le cas, cette particularité devra conduire l'Autorité délégante à respecter l'ensemble des procédures applicables dans cette situation et notamment consulter, pour avis, la DCMP.

En second lieu, si la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire n'est pas envisageable, l'Autorité délégante devra alors déterminer la procédure de passation la plus adaptée aux spécificités du contrat de délégation de service public.

En l'état actuel, l'Autorité délégante peut choisir entre :

- la procédure d'appel d'offres ouvert avec pré-qualification (exception, sauf pour les personnes publiques sans expérience dans le domaine des DSP) ;
- l'appel d'offres ouvert en deux étapes.

La sélection de l'appel d'offres en deux étapes doit être guidée par la nécessité de prendre en compte la complexité inhérente à la mise en œuvre du contrat. Cette complexité peut notamment résulter de l'importance des investissements à réaliser, ou de la technicité même du service public à déléguer (par exemple, le domaine de l'eau).

2.2. Déterminer les critères d'attribution du contrat

En matière de délégation de service public, l'Autorité délégante doit s'interroger sur les spécificités du service afin de choisir des critères d'attribution du contrat qui seront cohérents avec les objectifs qu'elle poursuit pour la gestion du service.

On retrouve majoritairement des critères classiques, tels que :

- les tarifs imposés aux usagers du service ;
- le montant de la subvention publique sollicitée ;
- l'atteinte d'objectifs de performances ;
- les engagements du délégataire pour assurer la qualité du service et l'améliorer tout au long du contrat ;
- le respect des normes environnementales ;
- la rationalité du financement des investissements lorsqu'il s'agit d'un contrat de concession.

Le choix des critères de sélection des offres peut revêtir un aspect véritablement stratégique pour les Autorités délégantes qui pourront sélectionner des offres dont les performances environnementales et sociales sont élevées.

2.3. Rédiger le dossier de consultation

2.3.1. Les pièces du dossier d'appel à la concurrence

L'étape suivante est naturellement la rédaction des documents d'appel à la concurrence conformément aux choix qui auront été effectués préalablement.

Ces documents sont regroupés dans un dossier d'appel à la concurrence qui devra contenir l'ensemble des pièces et documents nécessaires à la consultation.

En matière de délégation de service public, les principaux documents qui devront être rédigés par l'Autorité délégante sont les suivants :

- l'avis d'appel à la concurrence ;
- le dossier d'appel d'offres, y compris les données particulières ;
- les formulaires de soumission : formulaire de renseignement sur le candidat ou le groupement, un modèle de lettre de soumission, un modèle d'engagement à respecter la charte de transparence et d'éthique et le cas échéant, un modèle d'engagement de confidentialité ;
- le cahier des charges de la délégation de service public ;
- le projet de contrat, y compris les conditions particulières.

Le règlement de la consultation correspond à l'ensemble des règles qui s'appliquent aux candidats lors de la procédure de publicité et de mise en concurrence relative à l'attribution du contrat de délégation de service public. Il s'agit notamment des conditions de présentation des dossiers de candidature et des offres des soumissionnaires.

Le cahier des charges du contrat est un élément fondamental qui détermine les droits et obligations de chacune des parties. Il s'agit du « squelette » du futur contrat de DSP.

Ce document détermine de manière très détaillée les missions qui devront être assurées par le délégataire et les objectifs qui lui sont assignés. Il peut aussi comporter un plan d'exécution des travaux dans les contrats de concession.

Le cahier des charges comprend généralement les rubriques suivantes :

1. Objet, nature et caractéristiques du Contrat

- Objet et contexte
- Périmètre
- Durée
- Obligations générales du Délégataire
- Obligations générales du Délégant
- Caractéristiques générales du service (notamment continuité du service, égalité des usagers devant le service public, etc.)
- Caractéristiques techniques des ouvrages

2. Construction des ouvrages

- Droits conférés et obligations du Délégataire
- Contrôle par le Délégant
- Sous-délégation et sous-traitance
- Exécution des travaux
- Contrôle de l'exécution des travaux
- Procédure préalable à la mise en service de l'ouvrage
- Date de mise en service de l'ouvrage
- Modification de l'ouvrage

3. Exploitation de l'ouvrage

- Exploitation, entretien et maintenance
- Interruptions du service
- Obligations relatives au service public
- Agents et préposés du concessionnaire
- Exploitation des installations annexes

4. Régime financier du Contrat

- Principes financiers généraux
- Plan d'affaires
- Fixation des tarifs et publicité
- Recettes
- Équilibre financier de la délégation
- Redevance due par le Délégataire
- Investissement à la charge du Délégataire
- Garanties
- Responsabilité
- Pénalités
- Impôts et taxes
- Activités annexes

5. Dispositions générales

- Sous-délégation et sous-traitance
- Inventaire des biens du Contrat
- Répartition de la maîtrise d'ouvrage des travaux
- Déchéance
- Compte rendu d'exécution du Contrat
- Contrôle
- Force majeure et Causes Exonératoires
- Résiliation
- Retour et reprise des ouvrages en fin de concession

6. Dispositions diverses

- Cession du Contrat
- Litiges, recours et contentieux
- Annexes

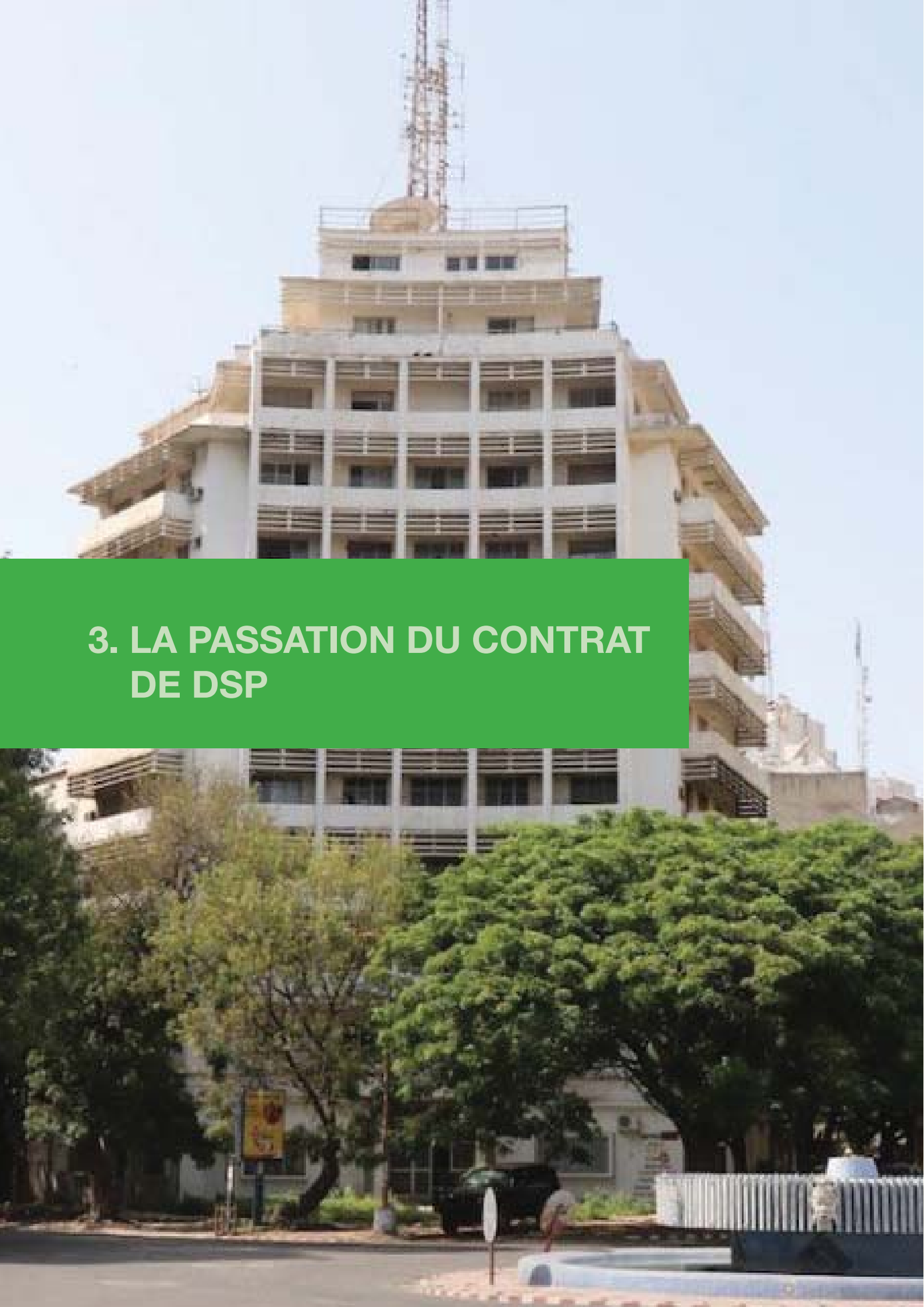
2.3.2. La consultation de la DCMP

Enfin, une fois ce dossier d'appel à la concurrence rédigé, l'Autorité délégante est tenue de le transmettre à la DCMP qui, conformément à nos recommandations, doit se voir attribuer un délai légal pour valider les pièces constituant le dossier d'appel à la concurrence, et émettre un avis.

À l'expiration de ce délai, l'absence de la réponse de la DCMP est considérée comme un avis favorable, et l'Autorité délégante peut alors poursuivre la passation du contrat (l'idéal serait cependant d'informer l'ARMP dans un tel cas).

Dans cette situation, l'Autorité délégante se trouve face à l'alternative :

- modifier lorsque cela est possible les pièces du dossier qui étaient à la source des réserves ou de l'avis défavorable de la DCMP ; ou
- passer outre l'avis de la DCMP. Dans ce cas, elle sera tenue :
 - de motiver sa décision par écrit ;
 - d'en rendre compte à l'autorité d'approbation du contrat ;
 - de requérir l'autorisation de l'Autorité de Régulation des Marchés publics.



3. LA PASSATION DU CONTRAT DE DSP

Toutefois, la DCMP peut aussi émettre un avis défavorable, ou un avis favorable assorti de réserves à l'encontre du dossier d'appel à la concurrence.

3.1. Organiser la publicité des documents de la consultation

3.1.1. La publication du dossier d'appel à la concurrence

Le lancement véritable de la procédure commence par la publication du dossier d'appel à la concurrence contenant l'ensemble des pièces et documents nécessaires à la consultation des opérateurs.

Parmi ces documents, un avis d'appel à la concurrence doit être impérativement publié conformément à l'article 82.4 du Code des Marchés publics. Il est destiné à informer les candidats potentiels à l'attribution d'un contrat de délégation de service public des caractéristiques essentielles de ce contrat.

L'avis d'appel public à la concurrence contient, en général, les informations suivantes :

1) les informations sur l'Autorité délégante :

- le nom et l'adresse de l'Autorité délégante ;
- un point de contact auprès de cette autorité (nom et adresse électronique) ;

2) les informations sur l'objet de la DSP ;

- un intitulé de la délégation de service public ;
- le texte en application duquel la convention est conclue ;
- un descriptif assez détaillé de l'objet du contrat ;
- la durée du contrat ;
- le lieu principal d'exécution ;

3) les conditions de participation à la consultation ;

- la liste des documents exigés au titre de la capacité économique et financière des candidats ;
- la liste des documents exigés au titre de la capacité technique des candidats ;
- la liste des documents exigés au titre de la capacité professionnelle des candidats ;

4) la procédure :

- le numéro de référence attribué au dossier par l'autorité délégante ;
- les modalités de présentation des candidatures ;
- la date limite de réception des candidatures ;
- les critères de sélection des offres qui peuvent être précisés dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans les documents qui seront remis aux candidats présélectionnés ;

5) les procédures de recours :

- le nom et l'adresse de l'autorité à saisir pour introduire un recours.

3.1.2. Support de la publication

L'Autorité délégante doit publier l'avis à la concurrence et le dossier d'appel à la concurrence sur différents supports au niveau interne et, le cas échéant, au niveau de l'UEMOA.

Au niveau national, l'avis d'appel à la concurrence devra être publié sur le portail officiel des marchés publics et dans au moins un journal quotidien de grande diffusion. À cet égard, l'Autorité délégente doit choisir avec le plus grand soin le journal qui sera le support de la publicité afin de cibler un public pertinent et assurer une information la plus large possible.

Au niveau de l'UEMOA, la publication de l'avis d'appel à la concurrence ne devra être mise en œuvre que lorsque le montant estimé du contrat à conclure sera supérieur ou égal au seuil de communautaire de publicité.

Dans cette situation, l'Autorité délégente doit veiller à ce que la publication de l'avis d'appel à la concurrence au niveau national n'intervienne pas avant la publication de l'avis au niveau communautaire.

3.2. Procéder à la sélection des candidatures

Conformément aux stipulations du règlement de la consultation, un délai est fixé aux candidats intéressés pour déposer un dossier de candidature.

La présélection, le cas échéant, des candidats qui seront invités à déposer une offre à l'Autorité délégente constitue une étape supplémentaire mais elle permet, en réalité, à la personne publique de ne pas examiner un nombre d'offres qui serait nécessairement plus important.

La phase de sélection des candidatures doit permettre à l'Autorité délégente de présélectionner les candidats présentant les aptitudes financières, techniques et professionnelles pour exécuter correctement le contrat et assurer la continuité du service public.

Au cours de cette phase, l'Autorité délégente devra aussi s'assurer que les candidats potentiels ne sont pas soumis à une interdiction de soumissionner (sont admissibles). Toutefois, afin de ne pas alourdir la procédure, l'Autorité délégente doit demander aux candidats de produire une attestation sur déclaration attestant :

- de leur respect de la charte de transparence et d'éthique ;
- qu'ils ne sont soumis à aucune interdiction de soumissionner par la réglementation.

A cet égard, il convient de souligner qu'il pourra être ensuite exigé de l'attributaire pressenti de remettre, avant toute signature de la DSP, divers justificatifs émanant notamment de l'administration.

3.2.1. Les justifications exigées

L'Autorité délégente doit veiller à ce que les critères de sélection des candidatures qu'elle prévoit soient directement liés à l'objet du contrat de délégation de service public et proportionnés.

3.2.1.1. Interdictions de soumissionner

Les interdictions de soumissionner telles que formulées, en matière de marchés publics, à l'article 43 du Code des Marchés publics, ont vocation à protéger les personnes publiques

contre les risques de fraude et de défaillance du titulaire du contrat de marché public. Les mêmes interdictions de soumissionner peuvent être mises en œuvre en matière de convention de délégation de service public.

En pratique, il est recommandé à l'Autorité délégante d'exiger des candidats la signature d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne se trouvent soumis à aucune interdiction de soumissionner. Cette pratique permet, en effet d'alléger les dossiers de candidature en n'exigeant pas de l'ensemble des candidats qu'ils apportent la preuve qu'ils ne se trouvent pas soumis à une interdiction de soumissionner.

À l'issue de la procédure, seul le candidat auquel il sera envisagé d'attribuer la convention de délégation de service public devra produire les documents attestant qu'il ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner.

Dans l'hypothèse où cet opérateur ne pourrait pas apporter la preuve qu'il n'est pas soumis à une interdiction de soumissionner ou s'il se trouve effectivement dans cette situation, l'Autorité délégante ne pourra lui attribuer le contrat et devra sélectionner l'opérateur ayant présenté la deuxième meilleure offre.

3.2.1.2. Capacités techniques

Les capacités techniques renvoient aux moyens matériels et humains dont disposent les candidats à l'attribution d'une convention de délégation de service public. Elles sont appréciées qualitativement et quantitativement.

Les capacités techniques pouvant être exigées des candidats sont, par exemple, l'ensemble des documents de présentation générale de l'entreprise, l'actionnariat, le personnel employé par l'entreprise, les moyens techniques (nombre de machines, technologie utilisée, etc.) dont elle dispose pour exécuter le contrat.

3.2.1.3. Capacités professionnelles

Les capacités professionnelles des candidats permettent de vérifier si le candidat dispose des qualifications requises ou, au moins, d'un certain niveau de compétences professionnelles.

Dans cette perspective, l'Autorité délégante peut exiger que le candidat produise un ou plusieurs certificats de qualifications professionnelles (certificats délivrés par des organismes professionnels) ou des certificats de qualité (certificats attribués par un organisme certificateur, norme ISO, etc.).

Plus généralement, il est demandé aux candidats de présenter les références dont ils disposent dans le domaine concerné par le contrat au cours des trois ou cinq dernières années.

3.2.1.4. Capacités financières

Le processus de présélection doit permettre de favoriser la participation des soumissionnaires de qualité. Les ressources financières constituent le principal critère d'évaluation de la capacité financière des candidatures. L'Autorité délégante se doit de s'assurer de la capacité des candidats à :

- prendre en charge les obligations financières applicables ;
- susciter l'intérêt des financeurs ;
- mettre en œuvre le projet de DSP dans son intégralité, au travers de leurs expériences précédentes.

Dans le cas de consortium de candidats, ce sont les capacités financières consolidées du groupe qui sont évaluées.

Par ailleurs, l'Autorité délégante a le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour favoriser la sélection d'acteurs du marché local, par exemple en réduisant le poids des critères financiers.

3.2.2. Retenir 3 à 5 candidats

L'ouverture des dossiers de candidature transmis par les candidats est opérée par la cellule de passation des contrats qui dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles, techniques et financières.

La phase de pré-sélection des candidatures doit permettre de sélectionner les candidats qui disposent effectivement des capacités permettant d'exécuter dans les meilleures conditions le contrat et d'assurer la continuité du service public.

Il est de bonne pratique de sélectionner 3 à 5 candidats qui seront admis à présenter une offre, la sélection d'un nombre limité de candidats étant la garantie qu'un dialogue de qualité pourra être mené avec chacun d'entre eux.

Pour cette raison, il est nécessaire d'établir dans l'avis d'appel à la concurrence que le dialogue ne pourra être engagé qu'avec un nombre restreint de candidats, idéalement entre trois et cinq candidats.

À l'issue de cette phase, l'Autorité délégante invite les entreprises présélectionnées à une offre sur le fondement des documents qui leur ont été transmis et notamment le cahier des charges de la délégation de service public.

3.2.3. Indemnisation des candidats non retenus

Le fait de prévoir de ne retenir qu'un nombre restreint de candidats peut avoir un effet néfaste sur l'attractivité du contrat.

En effet, la constitution d'un dossier de candidature nécessite un investissement de ressources non négligeables pour un résultat incertain de la part des opérateurs privés.

Afin de préserver l'attractivité du projet, l'Autorité délégante peut, dans certains cas, envisager d'indemniser les dépenses engagées par les candidats non retenus pour déposer un dossier de candidature.

3.3. Négocier avec les candidats présélectionnés

3.3.1. Le délai de présentation des offres

Le délai de présentation des offres doit être fixé dans le règlement du dossier d'appel d'offres (un délai minimal pourrait également être précisé dans les textes). En l'état actuel, le code

des marchés publics ne fixe pas de délai de présentation des offres en matière de convention de délégation de service public.

Un délai minimal de 45 jours calendaires à compter de l'invitation des candidats présélectionnés à déposer une offre peut idéalement être retenu, en conformité avec les prescriptions en vigueur en zone UEMOA.

3.3.2. La libre négociation des offres

À la suite de la réception des offres, une phase de libre négociation doit être engagée avec les candidats. Ces négociations doivent porter sur le contenu des offres présentées et doit permettre de faire évoluer les offres dans un sens favorable à l'Autorité délégante.

Les entreprises candidates peuvent alors être amenées à consentir des évolutions substantielles du contenu de leur offre.

En fonction du nombre de candidats retenu et de la complexité du projet (notamment en matière de concession comprenant des investissements importants), la durée de la négociation entre l'Autorité délégante et les candidats peut être plus ou moins longue.

Une période de deux mois environ doit, en principe, permettre de mener des négociations de bonne qualité.

À NOTER

Pour mémoire : En droit français, le dialogue compétitif est l'une des modalités de passation d'une DSP, dans laquelle l'Autorité délégante dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue sont invités à remettre une offre.

Le dialogue compétitif présente l'avantage de conférer une vision plus complète et comparative des solutions techniques, financières ou juridiques que le marché peut offrir, puisque les offres ne seront pas, dès le début, enfermées dans des spécifications techniques trop précises.

Si cette procédure doit être par principe prévue, elle pourra être utilement réservée à des offres au-delà d'un certain seuil qu'il conviendra de définir.

3.3.3. Les principes cardinaux à respecter

Lors de cette phase de négociation, l'Autorité délégante doit veiller à respecter scrupuleusement les principes fondamentaux issus de l'article 24 du COA, c'est-à-dire les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Ainsi, le respect du principe d'égalité impose, par exemple, que l'Autorité délégante offre des délais suffisants aux candidats pour présenter une offre modifiée et que ce délai soit le même pour l'ensemble des candidats.

En outre, le secret des offres et la confidentialité des négociations doivent être respectés afin de garantir le droit de propriété des candidats sur les offres qu'ils ont remises ainsi que la concurrence réelle entre les entreprises tout au long de la procédure.

Ainsi, les négociations doivent être menées de manière parfaitement étanche afin d'éviter que des informations notamment financières ne circulent et qu'un candidat ne puisse améliorer son offre au détriment d'un autre.

3.4. Sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse

À l'issue de la négociation, l'Autorité délégante doit avoir une bonne connaissance du contenu des offres remises par les candidats, éventuellement modifiées lors de la négociation.

En fonction des critères de sélection des offres retenus par la personne publique, au début de la procédure de passation, cette dernière doit être en mesure de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse.

L'offre économique la plus avantageuse est celle qui présente le rapport qualité - prix le plus intéressant.

En matière de délégation de service public, cela correspond plus précisément à l'offre présentant les meilleures garanties en matière de performance du délégataire, de qualité du service public et du tarif facturé aux usagers le plus intéressant pour eux.

L'Autorité délégante doit prendre une délibération afin d'officialiser le choix du délégataire de service public et notifier à ce dernier le choix de son offre.

3.4.1. Détermination des critères d'évaluation des offres

Les critères d'évaluation choisis par l'Autorité délégante se doivent d'être détaillés dans le dossier d'appel d'offres. Ces critères vont aider les candidats à établir leur dossier de réponse à l'appel d'offres. L'accès à ces critères est fondamental, il va permettre aux candidats de mieux comprendre les besoins du marché et ainsi d'orienter leurs réponses, les rendant ainsi plus qualitatives.

Il est difficile d'identifier les critères les plus pertinents au regard de la diversité des capacités techniques ou des montages commerciaux pouvant être présentés. Néanmoins, le choix des critères doit être minutieux et mis en perspective avec la volonté de l'Autorité délégante. En effet, les critères peuvent permettre à l'Autorité délégante de valoriser certains types de projets (projets innovants par exemple).

Les critères varient selon les contrats de DSP, néanmoins, les critères suivants peuvent être utilisés :

- Critères techniques :

- o Qualité de l'entrepreneur proposé et des sous-traitants ;
- o Technologie proposée et sa fiabilité ;
- o Calendrier de construction robuste et répondant aux délais prescrits ;
- o Planification d'achat du matériel, incluant la gestion de problèmes potentiels tels que les contraintes douanières, les contraintes de transport, les autres sources d'approvisionnement, etc. ;
- o Atténuation des risques environnementaux, sociaux et économiques ;
- o Régime d'exploitation, qualité de services à fournir, coûts du cycle de vie et régime d'entretien ;
- o Mesure dans laquelle le candidat souscrit aux conditions contractuelles proposées et aux autres documents proposés par l'État.

- Critères financiers :

- o Niveau des tarifs facturés aux consommateurs et au concédant ;
- o Solidité du modèle financier du candidat ;
- o Valeur actuelle de l'appui nécessaire de l'État ;
- o Niveau de partage des revenus/répartition des revenus/recettes ;
- o Solidité du plan de financement du candidat, précisant à quel moment la société de projet aura accès aux capitaux d'emprunts et aux fonds propres ; l'état d'avancement des efforts de due diligence des prêteurs et des investisseurs ; et dans quelle mesure les prêteurs s'engagent à financer le projet.

3.4.2. Modalités d'évaluation des critères

La méthode de notation consiste à donner une valeur chiffrée à une prestation, au regard d'un critère donné. Elle est indissociable des critères, puisqu'elle détermine la note attribuée au candidat pour chaque critère. Les critères peuvent être acceptés/refusés/notés.

Il est fondamental que l'Autorité déléguante définisse en amont de la procédure la méthode d'évaluation ainsi que le mécanisme de pondération des différents critères. Par ailleurs, il est recommandé de communiquer la méthode de notation et la pondération des critères aux candidats. Cela leur permettra de mieux comprendre les attentes et ainsi d'avoir une approche plus précise de leur offre.

3.4.3. Évaluation des offres

En règle générale, les offres seront d'abord évaluées au regard de critères binaires de type « reçu/rejeté ». Par ailleurs, il est impératif de vérifier que la solution technique proposée par les candidats est réalisable et robuste, qu'elle repose sur des technologies fiables, qu'elle remplit toutes les conditions techniques minimales fixées et que les coûts et la structure financière proposée sont cohérents avec la solution technique.

Il est important d'examiner également la solution proposée en matière de gestion de projet : un groupement candidat doit apparaître comme une entité cohérente et non comme une

juxtaposition d'entreprises rassemblées aux fins de la présentation d'une offre ou pour accéder au bénéfice de la marge de préférence.

Il arrive parfois qu'un seul candidat présente une offre alors que l'Autorité délégante a invité tous les candidats de la liste restreinte.

La démarche à adopter dans ce cas doit être étudiée au cas par cas :

- s'il s'avère que le manque d'intérêt des candidats résulte de lacunes du dossier d'appel d'offres (notamment du projet de contrat) auxquelles il paraît réaliste de remédier, la meilleure solution pourrait consister à recommencer la procédure de passation du contrat sur de meilleures bases ;
- s'il apparaît que le candidat a présenté une offre en partant du principe que la concurrence jouerait pleinement (ce qui peut être étayé par une analyse comparative des coûts effectuée par les conseillers de l'Autorité délégante et, dans certains cas, par une vérification des coûts effectuée sur la base d'un sondage de marché), la meilleure solution pourrait alors consister à poursuivre la procédure et à retenir l'unique candidat comme partenaire privé.

3.4.4. Classement des offres

L'évaluation des offres des candidats est faite selon les critères définis par l'Autorité délégante. Les offres sont donc classées, de la meilleure à la moins bonne.

Dans certains cas, plusieurs offres se placent en tête de classement. Ainsi, il est nécessaire d'organiser des tours supplémentaires pour mettre en concurrence ces offres. La gestion de ces tours supplémentaires doit se faire selon des règles précises :

- La transparence et l'équité doivent être préservées ;
- Toute tentative de corruption ou de favoritisme doit être évitée ;
- Une limitation des coûts supplémentaires ;
- Un respect du calendrier initial pour éviter la prise de retard lors de cette phase.

Les éclaircissements ou éventuels tours supplémentaires permettent à l'Autorité délégante de sélectionner la meilleure offre. L'offre retenue sera confirmée une fois les propositions de financement fermes et établies du contrat.

3.4.5. Transfert de technologie et de savoir-faire

Il peut être opportun de prévoir une clause par laquelle le Délégataire s'engage quantitativement et qualitativement sur les modalités de transfert de technologie et de savoir-faire, en intégrant notamment :

- un engagement chiffré en termes de recrutement de personnel sénégalais, notamment dans le top management de la société de projet créée le cas échéant ;
- un engagement sur un plan de formation d'agents de l'Autorité délégante ;
- des engagements en termes de transfert de technologie.

3.5. La fin de la procédure de passation

3.5.1. Information des candidats évincés

L'information des candidats non retenus à l'issue d'une procédure de délégation de service public est une formalité essentielle d'achèvement de la procédure au regard du principe de transparence rappelé par le Code des Obligations de l'Administration.

L'Autorité délégante procède à l'information des entreprises non retenues dès lors qu'elle a fait son choix pour une candidature ou pour une offre. À l'issue de l'examen des candidatures, l'acheteur public doit informer les entreprises dont la candidature n'a pas été retenue, sans attendre la fin de la procédure.

Puis, lorsque l'Autorité délégante a sélectionné le candidat auquel elle envisage d'attribuer le contrat, elle notifie aux candidats non retenus le rejet de leur offre. Dans ce cas, il est important de préciser le nom du candidat choisi et éventuellement les motifs qui ont conduit au choix de son offre.

Toutefois, pour ne pas alourdir considérablement les formalités auxquelles devront se conformer les Autorités délégantes, il ne devrait pas être nécessaire d'informer spontanément les candidats évincés des motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre.

Toutefois, si l'Autorité délégante reçoit une demande écrite d'un candidat évincé, sollicitant la communication des motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, elle devrait y répondre dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. La réponse à lui apporter ne portera que sur son offre/sa candidature.

3.5.2. La signature du contrat

La signature du contrat doit intervenir dans un délai relativement court suite à la notification, au candidat sélectionné, du choix de son offre et l'information des candidats évincés.

C'est généralement là que les candidats non retenus peuvent décider d'introduire un recours devant le Comité de Règlement des Différends de l'Autorité de Régulation des Marchés publics en se prévalant du non-respect par l'Autorité délégante des règles de publicité et de mise en concurrence.

Le contrat de DSP doit être signé par la personne habilitée à engager l'Autorité délégante ; il s'agit, en général, de l'exécutif de la personne publique ou, pour l'État, du ministère concerné.

Le signataire du contrat doit être le candidat retenu, se présentant dans la forme juridique dans laquelle il a déposé sa candidature et sur la base de laquelle il a été sélectionné.

Toutefois, il convient d'évoquer l'hypothèse dans laquelle le dossier de consultation imposerait ou permettrait de créer une société ad hoc, dédiée au projet. Dans ce cas, cette société pourra se voir céder le contrat de délégation de service public postérieurement à sa signature.

3.5.3. Publication d'un avis d'attribution

La publication d'un avis d'attribution du contrat permet de clôturer la procédure de passation du contrat et d'assurer l'information du public quant au Déléataire choisi et aux principales clauses du contrat.

Pour une meilleure gestion des contrats de DSP, il conviendrait que lesdits contrats soient enregistrés sur un registre géré par la DCMP. Ce registre devrait être tenu à jour et être utilisé pour le suivi des DSP signées.



4. L'EXÉCUTION DES CONTRATS DE DSP

Un modèle type d'avis d'attribution pourrait être adopté par voie réglementaire afin d'harmoniser les avis publiés par l'ensemble des Autorités délégantes au Sénégal. Ces avis doivent être publiés sur le portail des marchés publics et en fonction du montant du contrat attribué, au niveau de l'UEMOA.

4.1. Suivi et contrôle

4.1.1. Le contrôle de l'exécution du contrat

Le contrôle de l'exécution du contrat constitue une mission primordiale de l'Autorité délégante qui demeure responsable du service qui est rendu aux usagers. L'externalisation de la gestion d'un service public ne doit pas conduire l'Autorité délégante à s'en désintéresser. Tout d'abord, il appartient à l'Autorité délégante au moment de l'établissement du contrat et de la négociation avec les candidats, de définir les objectifs du contrôle. L'efficacité du contrôle opéré par la collectivité reposera en grande partie sur la pertinence de cette définition préalable des objectifs.

Trois objectifs principaux peuvent être assignés au contrôle d'un délégataire de service public :

- s'assurer de la bonne exécution des engagements contractuels du délégataire ;
- s'assurer de la régularité comptable, financière et tarifaire de la délégation ;
- recueillir les informations pertinentes sur la gestion du service.

Aussi, ce contrôle doit être adapté à la taille du service public et des objectifs assignés au délégataire. Une relation particulièrement étroite entre le délégataire et l'Autorité délégante doit s'instaurer dès le début de l'exécution du contrat.

En la matière, un certain nombre de bonnes pratiques peuvent être recommandées. Si cela est nécessaire, une visite des installations peut être organisée. En effet, l'Autorité délégante peut également visiter périodiquement les installations afin notamment de vérifier que le délégataire entretient bien les ouvrages et matériels mis à sa disposition.

L'assistance de conseils extérieurs est souvent nécessaire pour permettre à l'Autorité délégante d'exercer un contrôle efficace. À ce titre, il est tout à fait envisageable de mettre à la charge du délégataire une redevance de contrôle sous réserve que cette redevance corresponde au coût réel du contrôle.

4.1.2. Le rapport annuel

Le rapport annuel constitue un élément central du contrôle exercé par l'Autorité délégante sur le délégataire de service public.

Conformément à nos recommandations, il est de bonne pratique d'exiger du délégataire la production d'un rapport annuel permettant à l'Autorité délégante d'assurer le contrôle financier et technique de l'exécution du contrat.

Pour constituer un moyen de contrôle efficace, l'Autorité délégante doit exiger du délégataire qu'elle produise les éléments suivants :

- le compte annuel de résultat de l'exploitation du service public ;
- une analyse de la qualité du service rendu aux usagers du service public et des ouvrages comportant tout élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures envisagées pour améliorer la qualité du service rendu ;
- un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires au service public et un inventaire des biens de retour et des biens de reprise conformément aux stipulations du contrat ;
- un état de suivi du programme contractuel d'investissement (en ce qui concerne les concessions) et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service.

Ce rapport doit être produit une fois par an, à une date à déterminer.

Ce rapport annuel a aussi pour fonction d'informer le public et, plus précisément, les usagers sur la gestion effective du service public. Dans cette perspective, ce rapport doit être soumis à la commission consultative ou aux participants des audiences ou séances publiques afin qu'elle émette un avis sur le rapport remis par le délégataire et la qualité de la gestion du service public.

Ce rapport comporte classiquement les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la DSP et une analyse de la qualité de service, comportant en annexe un compte-rendu technique et un compte-rendu financier.

Il doit pouvoir être audité par l'Autorité délégante ou un représentant désigné par lui, généralement à ses frais.

La remise de ce rapport fait l'objet d'une réunion de présentation à l'Autorité délégante ainsi qu'au comité de suivi. Le projet de présentation est soumis à l'accord de l'Autorité délégante.

Il peut être contractuellement prévu que la non-production du rapport constitue une faute contractuelle qui est sanctionnée, dans les conditions à stipuler.

Ce rapport est constitué d'un compte rendu technique et d'un compte rendu financier qui, s'agissant des concessions, présentent notamment les informations reprises ci-dessous :

- Comptes rendus techniques

Les comptes rendus techniques ont pour objet d'étudier la qualité de service rendu aux usagers.

Au titre des comptes rendus techniques, il peut être prévu que le Délégataire fournisse au moins les indications suivantes :

Au titre des travaux neufs, selon les situations :

- les travaux de premier établissement effectués ;
- les travaux de renouvellements effectués ;
- les cas échéant, les travaux de raccordement et les extensions particulières ;
- le cas échéant, les justificatifs relatifs aux travaux non réalisés ;
- les dépenses réelles et les sommes facturées ;
- les travaux de modernisation ;
- le plan de réseau logique et physique mis à jour.

Au titre de l'exploitation :

- le journal des pannes et des interventions par le Déléгатaire, par opération - individualisée et en cumulé par nature ;
- les travaux de maintenance préventive et curative ;
- les travaux de modernisation ;
- le journal des pannes et des interventions par le Déléгатaire par nature et en cumulé ;
- le cas échéant, les statistiques de disponibilité du réseau (statistiques de disponibilité mois par mois et par type de service) ;
- le cas échéant, l'état de réservation des capacités du réseau mois par mois ;
- l'état des actions commerciales menées dans le courant de l'exercice concerné ;
- l'état des actions commerciales menées dans le courant de l'exercice concerné ;
- la présentation des événements prévus dans l'année à venir (extension, modification, raccordements, ...) et susceptibles d'affecter les services fournis ;
- les enquêtes de satisfaction des usagers réalisées au moins tous les [•] ans (à déterminer) ;
- le cas échéant, toute autre information ou document qu'il serait impératif de fournir en vertu d'une disposition légale nouvelle ;
- le cas échéant, les justificatifs liés aux prestations non réalisées ;
- les matrices de trafic écoulé ;
- etc.

Comptes rendus financiers :

Il peut être prévu que le compte-rendu financier établi par le Déléгатaire devra comporter au moins les documents suivants :

- en dépenses, à l'appui du compte-rendu technique, le détail des dépenses et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur, ventilées selon les dispositions du plan comptable ;
- un inventaire actualisé des actifs immobilisés au titre de la délégation et leur classement par nature. Cet inventaire présenterait par les biens de la DSP (biens de retour et biens de reprise), les biens propres et ce en valeur brute et en valeur nette. Il indiquerait clairement la date de début et la règle d'amortissement de chaque bien ;
- le programme de travaux réalisés et restant à réaliser ;
- les tableaux d'amortissement ;
- le détail des provisions passées ;
- le détail des justificatifs des redevances versées à l'Autorité délégante ;
- le bilan, compte de résultat ainsi que les annexes de l'exercice passé, après certification des comptes par le commissaire aux comptes ;
- la note du Commissaire aux Comptes ;
- une note explicative du passage des comptes de bilan et de résultat aux comptes analytiques d'exploitation ;
- un compte d'exploitation prévisionnel pour les [•] (à déterminer) exercices suivants et un comparatif par rapport au compte d'exploitation prévisionnel ;
- le cas échéant, un plan de financement prévisionnel pour les travaux de renouvellement et d'extension du réseau prévus ;
- les conventions passées avec la ou les maisons mères (convention d'assistance générale, mise à disposition de personnel, conventions de comptes courants, prestations de services, etc.) ;

- les conventions de prêt et les tableaux d'amortissements des emprunts ainsi que les actes de garanties qui y sont attachés ;
- la décomposition du chiffre d'affaires ;
- le cas échéant, toute autre information ou document qu'il serait nécessaire de fournir en vertu d'une disposition légale impérative nouvelle.
- plus généralement, toutes les informations financières relatives aux emprunts ou financements contractés, aux garanties mises en œuvre par le Délégataire et qui sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'équilibre du service public.

Cette liste n'est pas exhaustive et les Parties peuvent prévoir qu'elle sera complétée et ajustée pendant toute la durée de la Délégation de service publique sur simple demande écrite de l'Autorité délégante.

- Annexe au compte-rendu financier relatif aux conditions d'exécution du service public
 Dans le cadre d'une annexe au compte rendu financier, le Délégataire précisera toutes les difficultés rencontrées lors de la gestion du service public.

En outre il devra faire état :

- de ses effectifs : nombre et qualifications des agents, évolution de leur rémunération, taux de rotation et absentéisme, etc. ;
- des perspectives d'évolutions : nombre d'utilisateurs, services proposés, etc.

4.1.3. Détermination des responsabilités

Après signature du contrat de DSP, la responsabilité de qui est transmise à une équipe spécifique, « l'équipe de pilotage », choisie par l'Autorité délégante et présidée par un directeur. Elle sera en charge de la gestion du contrat au quotidien par le biais de processus et d'instruments explicités au préalable dans un guide d'administration du contrat.

Avant ce transfert de responsabilité l'entité publique devra veiller à ce que les conditions suivantes soient vérifiées :

- les responsabilités sont clairement définies, en nommant une équipe responsable de la gestion du contrat en parallèle de l'équipe de gestion de projet ;
- toutes les stipulations concernant les modifications du contrat en cours sont prises ;
- les ressources budgétaires et humaines sont suffisantes pour assumer la gestion du contrat.

Il est important pour l'Autorité contractante de définir clairement, avant le choix du partenaire privé, les modalités de fonctionnement de l'équipe en charge de la gestion du contrat. Les partenaires doivent être informés de la fréquence et de la teneur des informations qui leur sont demandées.

Par ailleurs, l'équipe de pilotage doit définir, en accord avec les différentes parties prenantes, l'ensemble des tâches dont chaque partie sera responsable.

4.1.4. Suivi de la performance du contrat

Afin de surveiller efficacement la performance du contrat de DSP, un dispositif de suivi de la performance du projet de DSP doit être mis en place. Ce dispositif prévoit que la société

délégataire doit transmettre, à intervalles réguliers, des données opérationnelles et financières à l'équipe de pilotage afin que cette dernière puisse évaluer en continu l'avancement du contrat.

Ce transfert d'information doit se tenir de manière régulière, néanmoins, il est impératif que la transmission des documents ne représente pas une charge trop importante pour la société délégataire. Le cas échéant, cette charge pourrait peser sur l'avancement général du contrat.

Ainsi, ce suivi de la performance doit permettre à l'équipe de pilotage de s'assurer régulièrement de :

- Vérifier l'atteinte des objectifs de performance ;
- Veiller à ce que les procédures de contrôle et d'assurance soient en place et efficaces ;
- Réaliser des rapports d'avancement du projet.

Parallèlement au suivi de la performance, l'équipe de pilotage aura la responsabilité d'appréhender et gérer les différents risques :

- Les risques liés au projet et contractuellement répartis entre les parties ;
- Les risques intrinsèques supportés par l'entité publique ;
- Les risques liés au projet et non affectés contractuellement ;
- Les risques associés aux changements du contrat.

Les procédures de résolution des risques doivent être détaillées dans le guide d'administration du contrat.

4.2. Les modifications du contrat de DSP

Les conventions de délégation de service sont des contrats de longue durée. Il est donc normal qu'une modification du contrat puisse être prévue pour permettre l'évolution du service et son adaptation aux besoins des usagers.

La modification du contrat peut intervenir selon deux modalités :

- par une décision unilatérale de l'Autorité délégante ;
- par la conclusion d'un avenant avec le délégataire.

Dans ces deux cas, les modifications du contrat sont strictement encadrées afin d'éviter qu'elles ne constituent un détournement des procédures de publicité et de mise en concurrence.

Le Code des Obligations de l'Administration limite ainsi sensiblement la possibilité pour les parties de modifier les contrats de DSP puisqu'une modification peut avoir pour objet :

- de modifier l'objet du contrat de délégation de service public ;
- de bouleverser l'équilibre économique du contrat.

Cela serait le cas, par exemple, si une modification conduit à augmenter le volume des investissements mis à la charge du délégataire, le prix, la nature des prestations ou encore le risque d'exploitation qu'il assume.

L'objet du contrat de délégation de service public est, par exemple, modifié lorsqu'un ave-

nant met à la charge du délégataire des investissements conduisant à la réalisation d'un ouvrage dissociable des ouvrages déjà construits.

En conséquence, l'Autorité doit, en premier lieu, veiller au respect des principes encadrant strictement les possibilités de modifier un contrat de délégation de service public en cours d'exécution.

4.2.1. Les modifications unilatérales

Le pouvoir de modifier unilatéralement le contrat résulte du principe de mutabilité du service public, lequel doit pouvoir être adapté à l'évolution des techniques ou des besoins des usagers.

Le pouvoir de modification unilatérale peut porter sur la consistance du service, les modalités d'exploitation, mais aussi les clauses tarifaires. Le refus du cocontractant de se soumettre aux modifications décidées par l'Autorité délégante peut constituer une faute, et justifier, dans les cas les plus graves, la résiliation du contrat.

La modification unilatérale du contrat donne lieu à l'indemnisation intégrale du délégataire de service lequel ne doit pas supporter les conséquences des choix de l'Autorité délégante pour la gestion du service public. Cette indemnisation doit porter :

- sur les investissements réalisés et non amortis;
- sur le manque à gagner, réduit et calculé selon des modalités qu'il conviendra de préciser contractuellement.

Il convient de noter que la loi octroie au régulateur un pouvoir de modification. C'est le cas du régulateur sectoriel dans le domaine de l'électricité.

4.2.2. Rédiger un avenant

La conclusion d'un avenant modifiant certaines clauses du contrat de délégation de service public est libre, sous réserve, toutefois, des limites posées par la réglementation en la matière.

En effet, dans la mesure où la passation du contrat initial est soumise à des règles, la liberté de conclure des avenants ne doit pas constituer un moyen de détourner les procédures de passation, notamment les obligations de publicité et de mise en concurrence. L'Autorité délégante, qu'elle soit ou non à l'initiative de la conclusion de l'avenant, doit s'assurer, dans tous les cas, que la conclusion de cet avenant ne revient pas à signer, en réalité, un nouveau contrat.

L'avenant ne doit pas modifier l'objet du contrat de délégation de service public, ni bouleverser l'équilibre général du contrat en modifiant substantiellement, par exemple :

- la durée du contrat ;
- le volume des investissements ;
- la nature des prestations ;
- le risque d'exploitation.

En dehors de ces cas, la conclusion d'un avenant peut notamment être justifiée pour prolonger la durée d'une convention de délégation de service public, lorsque cela est rendu nécessaire par un motif d'intérêt général.

En tout état de cause, la conclusion d'avenants doit être privilégiée par l'Autorité délégante afin de s'assurer de l'acceptation par le délégataire des modifications sollicitées et de leur bonne application, ensuite.

4.2.3. Refinancement

« Refinancer un projet » signifie renégocier le financement initial de la société projet à des conditions plus avantageuses. Le refinancement peut prendre des formes variables :

- Réduction de la valeur de la dette ;
- Extension de la période de remboursement de la dette ;
- Renouvellement d'une dette arrivée à maturité ;
- Augmentation du gearing (levier financier) ;
- Renégociation des taux, des garanties souscrites au lancement du projet.

Ainsi, le refinancement donne souvent lieu à des gains significatifs pour la société délégataire. Ces gains peuvent être justifiés par une bonne performance de la société délégataire, cependant, ils peuvent aussi résulter de facteurs macroéconomiques ou d'une plus grande confiance des prêteurs sur un marché de DSP spécifique. Dans ce cas, les gains ne sont pas directement attribuables à la performance de l'entité privée et peuvent donner lieu à des tensions d'ordre politique. Le partage des gains entre la société délégataire et l'autorité délégante est souvent considéré comme approprié. Néanmoins, les modalités de ce partage doivent être décrites au préalable dans le contrat de DSP.

4.3. Sanctionner son cocontractant

Le Code des Obligations de l'Administration connaît trois catégories de sanctions applicables au Délégataire de service public : la sanction résolutoire, les sanctions pécuniaires et les sanctions coercitives. La sanction résolutoire correspond à la résiliation pour faute du délégataire (cf. supra).

4.3.1. Choisir une sanction proportionnée

En dehors de la sanction résolutoire, l'Autorité délégante peut mettre en œuvre deux types de sanctions : les sanctions pécuniaires et la mise sous séquestre du Délégataire (sanction coercitive).

La mise en œuvre d'une sanction à l'encontre du délégataire doit être guidée par le souci de respecter un principe de proportionnalité entre la sanction prononcée et la gravité des manquements commis par le Délégataire.

Les sanctions pécuniaires et notamment les pénalités de retard constituent les sanctions les plus simples à mettre en œuvre pour l'Autorité délégante. Elles sanctionnent les manque-

ments du Déléataire de faible importance et notamment les retards d'exécution.

La détermination des manquements pouvant conduire au prononcé de cette sanction et les modalités de calcul de leur montant sont fixées dans la convention de délégation de service public.

Le recours aux sanctions coercitives et, plus précisément, à la mise sous séquestre du concessionnaire constitue une sanction moins courante car elle suppose que le délégataire soit responsable de manquements d'une particulière gravité.

Elle consiste pour l'Autorité délégante à se substituer provisoirement au Déléataire défaillant pour assurer, en son lieu et place l'exécution du service. Cette sanction est généralement mise en œuvre lorsque le Déléataire est temporairement incapable d'assurer la continuité du service public.

Avant de mettre en œuvre cette sanction, l'Autorité délégante doit toutefois s'interroger sur sa capacité à assurer elle-même temporairement le service public, ou, le cas échéant, trouver un tiers capable de l'assumer en lieu et place du Déléataire.

Cette situation provisoire est normalement suivie de la reprise de l'exploitation par le Déléataire. Toutefois, cette sanction coercitive peut être accompagnée d'une résiliation pour faute, en cas d'incapacité du Déléataire de reprendre l'exploitation du service.

4.3.2. Mettre en œuvre une sanction

La mise en œuvre d'une sanction correspond à l'ensemble des étapes et des procédures qui doivent être respectées par l'Autorité délégante en fonction de la sanction qu'elle prononce.

En général, plus la sanction prononcée est grave, plus les formalités qui entourent sa mise en œuvre sont importantes.

En premier lieu, s'agissant des sanctions pécuniaires, la convention de délégataire de service public définit le plus souvent la procédure devant être suivie par l'Autorité délégante pour prononcer ce type de sanction.

Il est donc loisible aux parties de prévoir que l'application de pénalités pécuniaires notamment pour sanctionner un retard ou l'indisponibilité d'un service, pourra avoir lieu à compter du simple constat du retard ou de l'inexécution. Ce caractère automatique des sanctions doit avoir été défini dans le contrat.

Si tel n'est pas le cas, l'application de pénalités financières peut être précédée d'une mise en demeure motivée assortie d'un délai. Cette mise en demeure doit faire état avec précision des manquements invoqués. L'application effective des sanctions ne peut ensuite intervenir qu'à l'issue du délai consenti au délégataire pour remédier aux manquements constatés.

En second lieu, il ne fait aucun doute que la mise sous séquestre du Déléataire est une sanction d'une gravité importante.

Elle devra donc toujours être précédée d'une mise en demeure assortie d'un délai suffisant pour permettre au délégataire de réagir.

Si, postérieurement à une mise en demeure, l'Autorité délégante entre en négociation avec

le délégataire pour examiner les solutions qu'il est susceptible de mettre en œuvre et que ces négociations échouent, il est recommandé à l'Autorité délégante l'envoi d'une nouvelle mise en demeure avant de prononcer effectivement la sanction.

Les conséquences de cette sanction pour le Délégataire sont, en général, les suivantes :

- il n'a plus droit à aucune rémunération ;
- il est privé de l'exercice de ses droits ;
- il supporte les coûts engendrés par la reprise temporaire de l'exploitation du service par un tiers ou directement par l'Autorité délégante.

La fin de la mise sous séquestre cesse dès que le Délégataire est, de nouveau, en mesure de remplir ses obligations.

4.4. La résiliation d'un contrat de DSP

La résiliation d'un contrat de délégation de service public conduit à la disparition du contrat pour l'avenir et de manière anticipée par rapport à l'échéance définie initialement à l'occasion de la procédure de passation.

4.4.1. Choisir le motif de la résiliation

En principe, le choix du motif de résiliation du contrat de délégation de service public ne pose pas de difficulté majeure.

On identifie plusieurs catégories de résiliation possibles des contrats de DSP :

- la résiliation à l'initiative de l'Autorité délégante qui comprend la résiliation pour motif d'intérêt général et la résiliation pour faute du Délégataire ;
- la résiliation à l'initiative du Délégataire, qu'il doit solliciter du juge ou de l'arbitre désigné selon les cas, lorsque l'Autorité délégante ne respecte pas ses obligations ou qu'il existe un cas de force majeure rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat ;
- la résiliation pour force majeure, envisagée à l'article 92 du COA, englobant des événements généralement qualifiés d'extérieur au débiteur, imprévisible au moment de la conclusion de la DSP, irrésistible (au sens « insurmontable »). Il convient de fixer limitativement la liste de ces événements (exemples : séisme, guerre, catastrophe naturelle) ;
- la résiliation à l'initiative commune des parties.

En fonction de la situation, l'Autorité délégante pourra mettre en œuvre ses pouvoirs exorbitants de résiliation unilatérale du contrat.

4.4.1.1. La résiliation pour motif d'intérêt général

La résiliation pour motif d'intérêt général constitue une hypothèse de résiliation sans faute du contrat. Les motifs d'intérêt général pouvant être invoqués par l'Autorité délégante sont par exemple :

- la modification des besoins à satisfaire dans le cadre du service public ;
- des considérations budgétaires propres à l'Autorité délégante ;

- la disparition du service public ou sa mutation structurelle ;
- l'abandon du projet en raison de difficultés techniques rencontrées dans le cadre de la réalisation du contrat ;
- la reprise en régie directe de l'exploitation du service qui avait été délégué ;
- les changements affectant le délégataire qui auraient pour conséquence qu'il ne présenterait plus les garanties requises pour l'exécution du contrat, etc.

Cette hypothèse de résiliation laisse donc une marge de manœuvre particulièrement importante à l'Autorité délégante.

Il convient de préciser que, dans un tel cas, le délégataire devrait en outre bénéficier du versement d'une indemnisation ne couvrant pas plus que :

- les investissements réalisés et non amortis;
- le manque à gagner réduit et calculé selon des modalités précisées contractuellement.

Il s'agit de ne pas rendre la mise en œuvre de la résiliation inopérante.

4.4.1.2. La résiliation pour faute

La résiliation pour faute correspond à la situation dans laquelle des manquements graves du délégataire conduisent l'Autorité délégante à mettre fin au contrat de manière anticipée. Il s'agit d'une décision particulièrement grave et qui comporte des conséquences importantes notamment pour la continuité du service public.

L'Autorité doit donc s'assurer que les manquements du Délégataire à ses obligations contractuelles revêtent une certaine gravité ou importance. Il s'agit dans cette hypothèse d'éviter que la déchéance du Délégataire ne soit prononcée pour des manquements mineurs, qui ne justifient pas l'adoption d'une décision aussi grave.

En tout état de cause, dans une telle hypothèse, le Délégataire ne saurait prétendre à une indemnisation.

4.4.1.3. La résiliation pour force majeure

La force majeure permet au Délégataire de se libérer de ses obligations contractuelles et, « si elle rend définitivement impossible l'exécution du contrat, constitue une cause légitime de résiliation de la convention ».

Dans une telle hypothèse, l'indemnisation à laquelle pourra prétendre le Délégataire doit être réduite aux investissements réalisés, et non amortis.

4.4.2. Respecter le principe du contradictoire

En matière de résiliation pour faute, l'Autorité délégante doit veiller à respecter toutes les obligations de forme et procédures dans pareille situation.

Il est de bonne pratique, pour l'Autorité délégante, d'envoyer préalablement à toute décision de sa part, une lettre de mise en demeure comportant les mentions suivantes :

- un exposé détaillé des manquements constatés au contrat ;

- une invitation du Déléataire à remédier à ses manquements ;
- une invitation du Déléataire à présenter ses observations sur le contenu de la lettre de mise en demeure.

Un délai raisonnable doit être laissé au Déléataire afin qu'il puisse éventuellement corriger ses défaillances et présenter des observations à l'Autorité délégante. Il s'agit ainsi de préserver le principe du contradictoire qui doit permettre au titulaire du contrat de répondre aux accusations formulées à son encontre.

Le principe qui doit guider l'action de l'Autorité délégante dans cette situation est qu'il lui appartient, dans chaque cas, de trouver une juste mesure entre les droits de la défense du titulaire du contrat en cas de faute grave commise par ce dernier et le prononcé de la résiliation, qui doit rester exceptionnelle.

4.4.3. Définir les modalités d'indemnisation

Les modalités d'indemnisation du Déléataire varient en fonction du motif de la résiliation du contrat de délégation de service public.

En premier lieu, lorsque l'Autorité délégante prononce la résiliation en raison de manquements du délégataire à ses obligations contractuelles, le principe est que le Déléataire ne peut obtenir l'indemnisation de la perte subie, ni de son manque à gagner.

En second lieu, l'hypothèse d'une résiliation pour motif d'intérêt général est celle où les droits du Déléataire sont les plus étendus. Cela se comprend aisément car la fin anticipée du contrat n'est pas imputable au Déléataire, directement ou indirectement.

C'est pourquoi il importe que l'Autorité délégante justifie, à la date à laquelle elle prend sa décision, que l'exploitation du service concédé doit être abandonnée ou établie sur des bases nouvelles.

Ce motif de résiliation ne doit pas donner lieu à indemnisation du Déléataire.

Le tableau ci-dessous présente les indemnités selon les motifs de résiliation de contrat de DSP.

Résiliation	Facteurs de déclenchement	Indemnités de résiliation
Manquement de la part de l'entité privée	- Non achèvement des travaux de construction ; - Non-respect persistant des critères de performance ; et - Insolvabilité de la société de projet. Les bailleurs de fonds bénéficient généralement de « droits d'inter-vention » pour leur permettre de résoudre des problèmes liés à une entreprise non performante. Le contrat peut être résilié uniquement si cette intervention est inefficace ou si les bailleurs de fonds choisissent de ne pas intervenir.	Les indemnités pour résiliation sont généralement définies pour que les actionnaires assument les charges liées au manquement. Les bailleurs de fonds peuvent aussi être exposés à une perte éventuelle (pour les inciter à corriger les problèmes) bien que cela n'ait aucune incidence sur la bancabilité. Les options sont les suivantes : - valeur intégrale ou ratio prédéfini de l'encours de la dette ; - valeur comptable dépréciée des actifs ; - valeur actualisée nette des flux de trésorerie futurs (en soustrayant les frais de résiliation) ; et - produits découlant d'un nouvel appel d'offres sur le libre marché : par conséquent, ceci permet aussi de surmonter la difficulté potentielle de trouver des fonds du budget pour remplir les obligations d'indemnisation pour résiliation intervenant de manière imprévue.
Manquement de la part du Déléataire	Le Déléataire n'est pas en mesure de remplir ses obligations conformément au contrat.	Un contrat équitable devrait assurer que l'entité privée ne soit pas perdante si l'entité publique choisit de manquer à ses obligations. Les indemnités pour résiliation dans ce cas ne doivent pas couvrir davantage que les investissements réalisés et non amortis, ainsi que le manque à gagner réduit et calculé selon des modalités contractuellement précisées.
Raisons d'intérêt général	De nombreuses lois relatives aux DSP/PPP ou à la passation de marchés publics permettent à l'entité contractante de résilier le contrat pour des raisons d'intérêt public.	Il convient de préciser que, dans un tel cas, le délégataire devrait en outre bénéficier du versement d'une indemnisation ne couvrant pas plus que (i) les investissements réalisés et non amortis et (ii) le manque à gagner réduit et calculé selon des modalités précisées contractuellement.
Cas de force majeure	Doivent être définis avec soin au contrat et se limiter aux événements prolongés de force majeure non assurables qui empêchent l'exécution des obligations.	Il s'agit de ne pas rendre la mise en œuvre de la résiliation inopérante. L'indemnisation à laquelle pourra prétendre le délégataire doit être réduite aux investissements réalisés, et non amortis.



5. LA FIN DES CONVENTIONS DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

DK-3146-SB

La fin des délégations de service public soulève des problématiques délicates. D'une part, la fin d'une délégation de service public est sensible car l'Autorité délégante doit s'assurer du sort des moyens techniques, humains, financiers affectés au service public jusqu'alors et d'autre part, de la préservation de la continuité du service public.

5.1. Conséquences financières de la fin de contrat

Les contrats de DSP doivent définir clairement la phase de transfert des actifs et des opérations lorsque le contrat arrive à terme. Il s'agit notamment de préciser la manière selon laquelle les actifs seront évalués, si le transfert des actifs se fera à titre gratuit ou onéreux, et comment le montant des paiements dus sera déterminé.

En règle générale, les DSP doivent être structurées de telle façon que l'Autorité délégante n'est redevable d'aucun montant au délégataire au terme normal du contrat. Néanmoins, le versement, à l'échéance du contrat, d'une somme équivalente à la valeur résiduelle des actifs peut être envisagé dans une situation où la durée de vie des actifs financés par le délégataire est particulièrement longue par rapport à la durée du contrat.

En cas de fin anticipée du contrat, les modalités d'indemnisation du Délégataire sont décrites supra.

5.2. Réaliser un inventaire des biens

La fin d'une délégation de service public suppose que l'Autorité délégante dispose d'une vision relativement précise du patrimoine affecté à l'exécution du service. Il est donc nécessaire de procéder à un inventaire de sortie de biens à la fois qualitatif et quantitatif.

L'un des intérêts de l'inventaire de sortie est d'identifier les différentes catégories de biens utilisés dans le cadre du contrat : biens de retour, biens de reprise et biens propres. Cet inventaire doit être dressé par le délégataire de service public, lequel doit pouvoir s'appuyer sur les différents rapports annuels remis à l'Autorité délégante tout au long du contrat.

Dans certains cas, l'établissement de l'inventaire de sortie peut s'avérer délicat si le suivi du patrimoine affecté au service public en cause n'a pas été effectué avec rigueur. Le recours à des expertises peut alors être recommandé.

La réalisation de cet inventaire doit permettre d'appliquer les stipulations du contrat de délégation de service public relatives au régime des biens.

En l'absence de stipulations particulières, il convient de rappeler que les biens de retour sont les biens nécessaires à l'exploitation du service public. Ils appartiennent ab initio à l'Autorité délégante.

Les biens de reprise sont les biens utiles mais non indispensables au service public. L'Autorité délégante a la faculté de reprendre ces biens, à l'issue du contrat, moyennant le paie-

ment d'un prix correspondant à la valeur vénale du bien.

La distinction entre ces deux catégories de biens comporte donc un enjeu financier très important pour l'Autorité délégante, d'où la nécessité de rédiger avec précision les clauses relatives à la répartition des biens dans le contrat.

L'inventaire des biens sert de point d'appui des parties en vue de l'évaluation des biens qui ne seraient pas amortis au moment de la liquidation du contrat, ce qui est notamment le cas, lorsqu'il est mis fin de manière anticipée à la convention.

Enfin, cet inventaire constitue un utile point de repère pour les candidats à l'attribution d'un nouveau contrat.

ÉVALUATION À LA DATE DE CLÔTURE

Évaluation des biens ayant une durée d'utilisation déterminable

Un bien ayant une durée d'utilisation déterminable est amorti par la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation. L'utilisation de l'actif doit être déterminable, c'est-à-dire qu'elle se mesure par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif selon un usage limité dans le temps. Il est alors possible de déterminer un montant amortissable par différence entre sa valeur initiale et sa valeur résiduelle estimée de façon fiable. La durée d'utilisation et le mode d'amortissement sont définis en fonction de la nature des actifs.

Évaluation des biens pour lesquels la durée de vie n'est pas déterminable

Un bien ayant une durée de vie indéterminable est évalué selon des règles différentes selon qu'il existe une valeur de marché observable ou pas .

Un expert indépendant pourrait opportunément être désigné, pour les besoins de l'expertise sur les biens et l'expertise en matière financière.

5.3. Assurer la continuité du service public

La fin d'une délégation de service public, surtout lorsqu'elle intervient au terme normal du contrat, ne doit pas entraîner de rupture dans le fonctionnement du service public.

En premier lieu, l'Autorité délégante doit pouvoir exiger du Délégataire sortant la transmission de l'ensemble des informations et des actifs immatériels nécessaires à la continuité du service public. Il peut s'agir, par exemple, de logiciels utiles à la gestion du service, ou des fichiers contenant des informations sur les usagers du service.

En second lieu, la continuité du service public et son bon fonctionnement impliquent également la reprise de certains contrats conclus par le délégataire. À cet égard, il est de bonne pratique de prévoir directement dans le contrat que l'Autorité délégante devra se substituer à son ancien délégataire pour l'exécution des contrats conclus avec les usagers ou avec d'autres tiers pour l'exécution du service.

Toutefois, cette substitution ne doit pas concerner les engagements anormalement pris par le délégataire, c'est-à-dire les engagements qui, au regard notamment de leur objet, de leurs conditions d'exécution ou de leur durée, ne pouvaient découler d'une interprétation raisonnable du contrat relatif à l'exécution du service public.

CONTRATS AVEC LES TIERS

Afin d'anticiper les incidences de la résiliation de la DSP sur les sous-contrats conclus par le Délégataire, il conviendrait de prévoir dans une clause qu'en cas de résiliation de la DSP, et quel qu'en soit le motif, les sous-contrats passés par le Délégataire pourront être transférés à l'Autorité délégante, ou à tout tiers que l'Autorité délégante pourrait désigner, à la seule discrétion de cette dernière.

Cette substitution :

- ne doit concerner que les engagements normalement pris pour l'exécution du service public. Sont réputés normalement pris les engagements du Délégataire qui n'excèdent pas le périmètre du contrat ;
- ne doit toutefois pas emporter transfert des dettes et créances nées de l'exécution antérieure des contrats concernés.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Il conviendrait que chaque DSP contienne une clause relative à la propriété intellectuelle (exemple : sur l'ouvrage réalisé, sur les logiciels utilisés, etc.) au titre de laquelle le Délégué cèderait intégralement ses droits de propriété intellectuelle, en fin de contrat (normale ou anticipée) à l'Autorité délégante.

Ainsi, la fin de la DSP ne doit impliquer aucune indemnisation supplémentaire du Délégué liée au transfert et/ou à la jouissance des droits de propriété intellectuelle nécessaires à la poursuite de l'exploitation du service délégué, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de tiers.

Le modèle de contrat joint à notre étude intègre une proposition de clause en ce sens.



6. RÈGLEMENT NON-JURIDICTIONNEL DES LITIGES : LE CAS DE L'ARBITRAGE

Aux termes de l'article 139 du CMP, les litiges relatifs aux contrats administratifs peuvent être soumis « à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l'Acte uniforme de l'OHA-DA relatif à l'arbitrage : les parties peuvent insérer une clause compromissoire dans les conditions prévues par le cahier des charges ».

L'Acte précité prévoit notamment que « les États et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les Établissements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage ».

Les DSP étant des contrats administratifs, il résulte de l'application combinée de ces textes qu'il est loisible aux parties de prévoir une clause compromissoire, leur permettant de substituer la compétence d'une juridiction arbitrale dont elle va déterminer la composition à celle du juge étatique : l'arbitrage est une justice conventionnelle.

Les avantages de l'arbitrage sont principalement les suivants :

- les parties peuvent choisir un ou des arbitres spécialistes du droit de la commande publique, et tenir compte de la multidisciplinarité que pourrait requérir une DSP sectorielle ;
- l'arbitrage est confidentiel. Les audiences ne sont pas publiques ;
- l'arbitrage est rapide, ne pâtissant pas de l'engorgement de certaines juridictions ;
- l'arbitrage élimine les conflits de compétence entre tribunaux, ainsi que généralement les problèmes de conflits de lois ;
- l'exécution forcée est possible partout.

Les parties pourront prévoir que leur litige soit soumis au Centre d'arbitrage et de médiation de Dakar, sur le plan national, mais aussi à tous les autres centres d'arbitrage : Cour commune de Justice et d'Arbitrage de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (CCJA), à Abidjan, la CCI à Paris, le Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI), l'Institut d'arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm, etc.



AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS

Rue Alpha Hachamiyou TALL x Kléber

B.P. 11 303 – DAKAR

TEL : +221 33 889 11 60 – FAX : +221 33 821 08 13

E-mail : armp@armp.sn – www.armp.sn – www.marchespublics.sn



**COOPÉRATION
SÉNÉGAL - LUXEMBOURG**

